

1502654-12.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gerdinaldo Quichaba Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 13ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/08/2022

... seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

13ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502654-12.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502654-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENILSON FELIX LIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gerdinaldo Quichaba Costa

Vistos.

DENILSON FELIX LIRA (RG 39113090-SP) foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº11.343/06, porque, no dia 31 de janeiro de 2022, por volta das 17h05, na Rua Escaravelho de Ouro, nº 281, Jardim Ângela, nesta cidade e comarca, teria trazido consigo, guardado e teria em depósito, para fins de comercialização, fornecimento e entrega a terceiros, drogas, consistentes em 849 (oitocentos e quarenta e nove) porções de "maconha", com peso líquido total de 3,2kg (quilogramas), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, em desacordo com autorização legal ou regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fls. 07/08) e, pelo Juízo de Plantão, sua prisão foi convertida em preventiva (fls. 66/70).

O acusado foi citado (fls. 112) e sobreveio aos autos sua Defesa Prévia (fls. 116/117), sendo recebida a denúncia (fls. 119).

Na primeira audiência de instrução foram ouvidas as testemunhas policiais.

Na audiência em continuação foi ouvida a testemunha remanescente, arrolada na

denúncia, e uma testemunha de defesa; ao final, o réu foi interrogado.

O Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, com aumento da pena base em razão da quantidade e variedade de drogas, o reconhecimento da reincidência e a fixação do regime fechado.

A Defesa, por sua vez, requereu absolvição do acusado, nos termos do art. 386, inciso II, III, VII do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação para figura prevista no art. 28 da lei de drogas; fixação da pena-base no mínimo legal; fixação de regime inicial diverso do fechado; e direito ao recurso em liberdade

É o relatório. Fundamento e decido.

Os laudos de constatação e definitivo químico-toxicológico comprovam que a droga apreendida era 3,2 kg de maconha.

Os policiais militares Jair Cardoso e Fernando Vorpini declararam, em fase policial, que foram acionados para averiguarem possível tráfico de drogas informado por denunciante anônimo via disk denúncia. Segundo noticiado, um indivíduo do sexo masculino armazenava entorpecentes dentro de um imóvel localizado na Rua Escaravelho de Ouro, 281, Jd. Ângela. Então, dirigiram-se até o local, ocasião em que vislumbraram o acusado na frente de uma residência. Os policiais afirmaram que o abordaram e, em revista pessoal, foram localizadas com o referido 10 (dez) pequenos sacos de, aparentemente, maconha. Em conversa informal, DENILSON, confessou que vendia as drogas. Disseram, ainda, que o acusado relatou ter guardado mais entorpecentes em um imóvel ali próximo, todavia, não indicou sua localização exata. Os policiais, então, destacaram que utilizaram da ajuda de um cão farejador, lograram êxito em localizar, em um imóvel inabitado, 839 (oitocentas e trinta e nove) porções de, aparentemente, maconha, sendo que parte estava armazenada em pequenos sacos de plástico e parte em pequenos tubos de acrílico. Ademais, na mesma ocasião, foram localizados diversos escritos de possível contabilidade do tráfico. Ato contínuo, ao indagarem DENILSON, este confessou que estes entorpecentes também estariam em sua posse para venda.

Em juízo, a testemunha policial Jair afirmou que estavam em patrulhamento e através de denúncia se dirigiram até a via e viram o acusado. Relatou que efetuaram abordagem e localizaram as drogas com o acusado, sendo que este confessou o tráfico no local. Contou que o cão farejador indicou um "barraco" inabitado com grande quantidade de droga. Relatou ter o réu confessado que as drogas achadas também eram dele. Informou que receberam a denúncia pelo disk denúncia informando que tinha armazenamento de drogas no local e tinha o número da residência. Relatou que o acusado estava próximo do local das drogas. Informou que os entorpecentes estavam em sacos plásticos. Não se recorda se tinha um familiar do acusado no local. Contou que na residência não tinham documentos que poderiam identificar o proprietário. Informou que o acusado estava a duas casas da viela que tinha a residência com as drogas.

Em juízo, a testemunha policial Fernando afirmou que foram averiguar uma denúncia a qual informava que um indivíduo traficava na frente de uma residência. Relatou que abordaram o acusado próximo do local indicado e localizaram entorpecentes com o acusado e este informou que tinha mais drogas em uma residência, mas não informou o local. Contou que o cão farejador indicou uma residência a qual localizaram um saco preto com mais entorpecentes. Relatou que a denúncia indicava o endereço do tráfico. Contou que o acusado estava próximo da residência em que foram localizadas as drogas. Informou que no local tinha uma cama e as drogas. Contou que não tinha nenhum objeto do acusado na casa, mas o acusado confessou posteriormente que a residência era a dele.

A testemunha em comum Creusa Félix da Silva narrou, em juízo, que é tia do réu, irmã da mãe dele, e não presenciou a abordagem. Afirmou que ele não faz uso de drogas e tem problema de saúde. Confirmou que o endereço dos fatos é a casa dela, que faz parede com a casa da mãe do réu. Aduziu que não há nenhum espaço ali em que ninguém resida e que alugou a sua casa para um rapaz chamado Michael, tendo-se em vista que mora em Peruíbe, para onde partiu após a morte do marido. Informou que o rapaz pagou somente o primeiro mês de aluguel e que foi a primeira vez que alugou o imóvel. Explicou que o local é um terreno com quintal, onde há 4 casas, em uma das

quais o réu mora. Esclareceu que, na época dos fatos, não morava lá, já que estava no litoral com sua filha. Asseverou que o contrato do aluguel foi verbal e não chegou a pegar o documento do inquilino, que só pagou um mês.

A testemunha Larissa Souza Silva narrou, em juízo, que no dia do acontecido, o réu estava em casa e saiu para ir ao mercado, quando a polícia o abordou. Disse que ela estava na rua na frente do portão. Informou que os cachorros invadiram a casa que estava alugada. Explicou que mora na esquina, não mora no mesmo local que o réu. Aduziu que ninguém tinha conhecimento sobre o que tinha na casa, pois estava fechada e a dona estava no litoral, nem conhecia a pessoa que alugou a casa. Afirmou que o réu foi pego na rua.

O réu afirmou em seu depoimento extrajudicial que estava caminhando na via pública, fumando um cigarro de maconha, quando foi abordado pelos policiais militares. Disse que, nesse momento, iniciou uma discussão com os castrenses e, logo depois, os policiais o conduziram até um imóvel que é de propriedade de sua tia CREUZA, onde foram localizados os entorpecentes. Instado, negou saber informar outros dados sobre CREUZA. Disse, ademais, que o imóvel em questão é alugado pela tia a um terceiro, o qual nega conhecer. Indagado, afirmou que reside em um imóvel vizinho ao local onde os entorpecentes foram localizados. Disse, ainda, que não visualizou o momento em que as drogas foram encontradas, pois não adentrou no local junto com os policiais. Outrossim, negou ter qualquer envolvimento com a venda de drogas. Questionado, negou saber ler e escrever. Em resposta às perguntas realizadas por seu advogado, o interrogado aduziu que foi capturado na rua de sua residência, a aproximadamente 100 metros de distância do local em que os entorpecentes foram localizados. Ademais, instado sobre ter acesso ao imóvel em que as drogas estavam armazenadas, afirmou ter acesso apenas ao quintal, pois é compartilhado entre seus familiares.

Em juízo, o réu negou os fatos. Disse que mora perto da casa da tia, que alugou o imóvel. Narrou que saiu para comprar pão e estava fumando maconha, quando os policiais o abordaram, perguntaram o seu nome e onde morava, e foram lá com os cães farejadores e acharam a droga. Negou que tenha sido encontrado com 10 sacos de maconha, só estava com um cigarro de maconha e 5 reais para comprar pão. Afirmou que foi abordado perto da casa, e que morava numa das 4 casas que ficam no mesmo quintal onde as drogas foram localizadas, que a droga foi localizada na casa da tia. Repetiu que foi abordado num lugar perto. Alegou que não chegou a ver se a casa estava fechada ou aberta e que não conhecia a pessoa que alugou.

Pelo que se depreende dos autos, havia uma denúncia anônima informando sobre a traficância no local dos fatos. Agentes da polícia militar, com base nessas informações, diligenciaram e localizaram o réu próximo ao local com 10 sacos contendo maconha e, com a indicação do acusado e com a ajuda de cães farejadores, encontraram mais drogas no local dos fatos.

Em relação à apreensão das drogas em posse do réu, verifica-se que não há comprovação material. Tanto no boletim de ocorrência (fls. 05/07), quanto no auto de exibição e apreensão (fls. 27) e nos laudos de constatação de substância (fls. 29/31) e químico-toxicológico definitivo (fls. 103/104), não há individualização dessas porções. Portanto, falta materialidade.

Por outro lado, quanto aos demais entorpecentes localizados dentro da casa, sem avançar no mérito das questões relacionadas à autoria, verifica-se que os policiais efetuaram uma ação precipitada, uma vez que, para que houvesse a devida apreensão das drogas naquele imóvel, os policiais, com posse da informação prévia da existência de traficância naquele local, deveriam ter a devida autorização de ingresso por meio de um mandado de busca e apreensão. Não foi o que aconteceu. O réu negou que residia naquela casa, que pertenceria a sua tia e seria alugada a uma terceira pessoa. O fato é que os policiais entraram no imóvel onde não se permitia o ingresso sem autorização. Não havia justificativa para a abordagem do réu, a não ser que realmente estivesse fumando maconha como dissera, mas os próprios policiais não confirmaram isso. Foi esse o tipo de situação que levou o Superior Tribunal de Justiça a tomar a decisão recente contra violação de domicílio.

Nesse sentido, o ingresso dos policiais no imóvel sem autorização judicial ou sem a prova do consentimento do morador, torna ilegal tudo que foi encontrado e, conforme

a teoria dos frutos da árvore envenenada, são nulas todas as provas derivadas do encontro das drogas, não sobrando, portanto, mais nada que incrimine a ré. Nesse sentido, já decidiu o referido Tribunal:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CONSENTIMENTO DO MORADOR. VERSÃO NEGADA PELA DEFESA. IN DUBIO PRO REO. PROVA ILÍCITA. NOVO ENTENDIMENTO SOBRE O TEMA HC 598.051/SP. VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR DEPENDE DE PROVA ESCRITA E GRAVAÇÃO AMBIENTAL. WRIT NÃO CONHECIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso XI, estabelece que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 3. Em recente julgamento no HC 598.051/SP, a Sexta Turma, em voto de relatoria do Ministro Rogério Schietti - amparado em julgados estrangeiros -, decidiu que o consentimento do morador para a entrada dos policiais no imóvel será válido apenas se documentado por escrito e, ainda, for registrado em gravação audiovisual. 4. O eminente Relator entendeu ser imprescindível ao Judiciário, na falta de norma específica sobre o tema, proteger, contra o possível arbítrio de agentes estatais, o cidadão, sobretudo aquele morador das periferias dos grandes centros urbanos, onde rotineiramente há notícias de violação a direitos fundamentais. 5. Na hipótese em apreço, consta que o paciente e a corré, em razão de uma denúncia anônima de tráfico de drogas, foram abordados em via pública e submetidos a revista pessoal, não tendo sido nada encontrado com eles. Na sequência, foram conduzidos à residência do paciente, que teria franqueado a entrada dos policiais no imóvel. Todavia, a defesa afirma que não houve consentimento do morador e, na verdade, ele e sua namorada foram levados à força, algemados e sob coação, para dentro da casa, onde foram recolhidos os entorpecentes (110g de cocaína e 43g de maconha). 6. Como destacado no acórdão paradigma, "Essa relevante dúvida não pode, dadas as circunstâncias concretas - avaliadas por qualquer pessoa isenta e com base na experiência cotidiana do que ocorre nos centros urbanos - ser dirimida a favor do Estado, mas a favor do titular do direito atingido (in dubio libertas). Em verdade, caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador." 7. Na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e consequentemente de toda a prova dela decorrente (fruits of the poisonous tree). 8. Vale anotar que a Sexta Turma estabeleceu o prazo de um ano para o aparelhamento das polícias, o treinamento dos agentes e demais providências necessárias para evitar futuras situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, resultar em responsabilização administrativa, civil e penal dos policiais, além da anulação das provas colhidas nas investigações. 9. Fixou, ainda, as seguintes diretrizes para o ingresso regular e válido no domicílio alheio, que transcrevo a seguir:

"1. Na hipótese de suspeita de crime em flagrante, exige-se, em termos de standard probatório para ingresso no domicílio do suspeito sem mandado judicial, a existência de fundadas razões (justa causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 2. O tráfico ilícito de entorpecentes, em que pese ser classificado como crime de natureza permanente, nem sempre autoriza a entrada sem mandado no domicílio onde supostamente se encontra a droga. Apenas será permitido o ingresso em situações de urgência, quando se concluir que do atraso decorrente da

obtenção de mandado judicial se possa objetiva e concretamente inferir que a prova do crime (ou a própria droga) será destruída ou ocultada. 3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a busca e apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação. 4. A prova da legalidade e da voluntariedade do consentimento para o ingresso na residência do suspeito incumbe, em caso de dúvida, ao Estado, e deve ser feita com declaração assinada pela pessoa que autorizou o ingresso domiciliar, indicando-se, sempre que possível, testemunhas do ato. Em todo caso, a operação deve ser registrada em áudio-vídeo e preservada tal prova enquanto durar o processo. 5. A violação a essas regras e condições legais e constitucionais para o ingresso no domicílio alheio resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência."

10. Habeas corpus não conhecido. Ordem, concedida, de ofício, para declarar a invalidade das provas obtidas mediante violação domiciliar, e todas as dela decorrentes, na AP n. 132/2.20.0001682-3. Expeçam-se, também, alvará de soltura em benefício do paciente e, nos termos do art. 580 do CPP, da corrê.

(STJ. HC: 616.584 – RS. Relator: Ministro Ribeiro Dantas. Julgado no dia 30 de março de 2021) (Grifo nosso)

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO. EXIGÊNCIA DE JUSTA CAUSA (FUNDADA SUSPEITA). CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE. ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. PROVA NULA. ABSOLVIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O art. 5º, XI, da Constituição Federal consagrou o

direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial". 1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias, perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade da ressalva a tal franquia constitucional exige. 1.2. O

direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar, mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the storm may enter, the rain may enter, but the King of England cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March 1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the Time of George III First Series (1845) v. 1). 2. O ingresso regular em

domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata – é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira urgência legítima o ingresso em domicílio alheio, como se infere da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei 12.850/2013 (art. 8º), que autorizam o retardamento da atuação policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva, a maior segurança e a

melhor instrumentalização da investigação – e, no que interessa a este caso, a proteção do direito à inviolabilidade do domicílio – justificam o retardo da cessação da prática delitiva. 2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar, mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar, de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez, ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é claro, da anulação – amiúde irreversível – de todo o processo, em prejuízo da sociedade. 3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), a tese de que: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori” (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não tiver alcançado o resultado esperado. 4. As circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude “suspeita”, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente. 5. Se, por um lado, práticas ilícitas graves autorizam eventualmente o sacrifício de direitos fundamentais, por outro, a coletividade, sobretudo a integrada por segmentos das camadas sociais mais precárias economicamente, excluídas do usufruto pleno de sua cidadania, também precisa sentir-se segura e ver preservados seus mínimos direitos e garantias constitucionais, em especial o de não ter a residência invadida e devassada, a qualquer hora do dia ou da noite, por agentes do Estado, sem as cautelas devidas e sob a única justificativa, não amparada em elementos concretos de convicção, de que o local supostamente seria, por exemplo, um ponto de tráfico de drogas, ou de que o suspeito do tráfico ali se homiziou. 5.1. Em um país marcado por alta desigualdade social e racial, o policiamento ostensivo tende a se concentrar em grupos marginalizados e considerados potenciais criminosos ou usuais suspeitos, assim definidos por fatores subjetivos, como idade, cor da pele, gênero, classe social, local da residência, vestimentas etc. 5.2. Sob essa perspectiva, a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos – diante da discricionariedade policial na identificação de suspeitos de práticas criminosas – pode fragilizar e tornar irritado o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar, a qual protege não apenas o suspeito, mas todos os moradores do local. 5.3. Tal compreensão não se traduz, obviamente, em cercear a necessária ação das forças de segurança pública no combate ao tráfico de entorpecentes, muito menos em transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos ou em espaço de criminalidade. Há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso policial no domicílio alheio a situação de ocorrência de um crime cuja urgência na sua cessação desautorize o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial – meio ordinário e seguro para o afastamento do direito à inviolabilidade da morada – legitimar a entrada em residência ou local de abrigo. 6. Já no que toca ao consentimento do morador para o ingresso em sua residência – uma das hipóteses autorizadas pela Constituição da República para o afastamento da inviolabilidade do domicílio – outros países trilharam caminho judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis, geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso alheio. 6.1. Nos Estados Unidos, por exemplo, a par da necessidade do exame da causa provável para a entrada de policiais em domicílio de suspeitos de crimes, não pode haver dúvidas sobre a voluntariedade da autorização do morador (*in dubio libertas*). O consentimento “deve ser inequívoco, específico e conscientemente dado, não

contaminado por qualquer truculência ou coerção ("consent, to be valid, 'must be unequivocal, specific and intelligently given, uncontaminated by any duress or coercion'"). (United States v McCaleb, 552 F2d 717, 721 (6th Cir 1977), citando Simmons v Bomar, 349 F2d 365, 366 (6th Cir 1965). Além disso, ao Estado cabe o ônus de provar que o consentimento foi, de fato, livre e voluntariamente dado, isento de qualquer forma, direta ou indireta, de coação, o que é aferível pelo teste da totalidade das circunstâncias (totality of circumstances). 6.2. No direito espanhol, por sua vez, o Tribunal Supremo destaca, entre outros, os seguintes requisitos para o consentimento do morador: a) deve ser prestado por pessoa capaz, maior de idade e no exercício de seus direitos; b) deve ser consciente e livre; c) deve ser documentado; d) deve ser expresso, não servindo o silêncio como consentimento tácito. 6.3. Outrossim, a documentação comprobatória do assentimento do morador é exigida, na França, de modo expresso e mediante declaração escrita à mão do morador, conforme norma positivada no art. 76 do Código de Processo Penal; nos EUA, também é usual a necessidade de assinatura de um formulário pela pessoa que consentiu com o ingresso em seu domicílio (North Carolina v. Butler (1979) 441 U.S. 369, 373; People v. Ramirez (1997) 59 Cal.App.4th 1548, 1558; U.S. v. Castillo (9a Cir. 1989) 866 F.2d 1071, 1082), declaração que, todavia, será desconsiderada se as circunstâncias indicarem ter sido obtida de forma coercitiva ou houver dúvidas sobre a voluntariedade do consentimento (Haley v. Ohio (1947) 332 U.S. 596, 601; People v. Andersen (1980) 101 Cal.App.3d 563, 579. 6.4. Se para simplesmente algemar uma pessoa, já presa – ostentando, portanto, alguma verossimilhança do fato delituoso que deu origem a sua detenção –, exige-se a indicação, por escrito, da justificativa para o uso de tal medida acautelatória, seria então, no tocante ao ingresso domiciliar, "necessário que nós estabeleçamos, desde logo, como fizemos na Súmula 11, alguma formalidade para que essa razão excepcional seja justificada por escrito, sob pena das sanções cabíveis" (voto do Min. Ricardo Lewandowski, no RE n. 603.616/TO). 6.5. Tal providência, aliás, já é determinada pelo art. 245, § 7º, do Código de Processo Penal – analogicamente aplicável para busca e apreensão também sem mandado judicial – ao dispor que, "[f]inda a diligência, os executores lavrarão auto circunstanciado, assinando-o com duas testemunhas presenciais, sem prejuízo do disposto no § 4º". 7. São frequentes e notórias as notícias de abusos cometidos em operações e diligências policiais, quer em abordagens individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade, academicismo e desconexão com a realidade conferir, em tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos abusivos. E, em um país conhecido por suas práticas autoritárias – não apenas históricas, mas atuais –, a aceitação desse comportamento compromete a necessária aquisição de uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais de todos, independentemente de posição social, condição financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça. 7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva a usual afirmação – como ocorreu no caso ora em julgamento – de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos policiais para a busca domiciliar, máxime quando a diligência não é acompanhada de documentação que a imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade. 7.2. Por isso, avulta de importância que, além da documentação escrita da diligência policial (relatório circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e áudio, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da criminalidade em geral – pela maior eficácia probatória, bem como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações contra policiais, por outro – e permitirá avaliar se houve, efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado. 8. Ao Poder Judiciário, ante a lacuna da lei para melhor regulamentação do tema, cabe responder, na moldura do Direito, às situações que, trazidas por provocação do interessado, se mostrem violadoras de direitos fundamentais do indivíduo. E, especialmente, ao Superior Tribunal de Justiça

competer, na sua função judicante, buscar a melhor interpretação possível da lei federal, de sorte a não apenas responder ao pedido da parte, mas também formar precedentes que orientem o julgamento de casos futuros similares. 8.1. As decisões do Poder Judiciário – mormente dos Tribunais incumbidos de interpretar, em última instância, as leis federais e a Constituição – servem para dar resposta ao pedido no caso concreto e também para “enriquecer o estoque das regras jurídicas” (Melvin Eisenberg. *The nature of the common law*. Cambridge: Harvard University Press, 1998. p. 4) e assegurar, no plano concreto, a realização dos valores, princípios e objetivos definidos na Constituição de cada país. Para tanto, não podem, em nome da maior eficiência punitiva, tolerar práticas que se divorciam do modelo civilizatório que deve orientar a construção de uma sociedade mais igualitária, fraterna, pluralista e sem preconceitos. 8.2. Como assentado em conhecido debate na Suprema Corte dos EUA sobre a admissibilidade das provas ilícitas (*Weeks v. United States*, 232 U.S. 383, 1914), se os tribunais permitem o uso de provas obtidas em buscas ilegais, tal procedimento representa uma afirmação judicial de manifesta negligência, se não um aberto desafio, às proibições da Constituição, direcionadas à proteção das pessoas contra esse tipo de ação não autorizada (“such proceeding would be to affirm by judicial decision a manifest neglect, if not an open defiance, of the prohibitions of the Constitution, intended for the protection of the people against such unauthorized action”). 8.3. A situação versada neste e em inúmeros outros processos que aportam a esta Corte Superior diz respeito à própria noção de civilidade e ao significado concreto do que se entende por Estado Democrático de Direito, que não pode coonestar, para sua legítima existência, práticas abusivas contra parcelas da população que, por sua topografia e status social e econômico, costumam ficar mais suscetíveis ao braço ostensivo e armado das forças de segurança. 9. Na espécie, não havia elementos objetivos, seguros e racionais que justificassem a invasão de domicílio do suspeito, porquanto a simples avaliação subjetiva dos policiais era insuficiente para conduzir a diligência de ingresso na residência, visto que não foi encontrado nenhum entorpecente na busca pessoa realizada em via pública. 10. A seu turno, as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, conseqüentemente, a formação de prova incriminatória em seu desfavor. 11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por derivação (art. 5º, LVI, da Constituição da República), é nula a prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de ilicitude) e a apreensão de drogas. 12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e conseqüente absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e distrital. 13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o aparelhamento das polícias, treinamento e demais providências necessárias para a adaptação às diretrizes da presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e/ou penal do agente estatal. (STJ. HC: ° 598.051 – SP. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Julgado no dia 02 de março de 2021.)

Portanto, de rigor, o reconhecimento da ilicitude da prova localizada dentro do imóvel, já que obtida por meio de invasão de domicílio, e da não comprovação da apreensão de entorpecentes na posse do réu, com a sua conseqüente absolvição por



ausência da materialidade do crime de tráfico.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido acusatório e, por consequência, nos termos do artigo 386, inciso II do Código de Processo Penal, ABSOLVO o réu DENILSON FELIX LIRA (RG 39113090-SP) da imputação de ter infringido o disposto no artigo 33, caput, da Lei Federal 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a destruição da substância entorpecente apreendida.

Em relação ao telefone celular apreendido, fica autorizada a restituição ao proprietário. Comunique-se à autoridade policial.

Após, com as comunicações e cautelas de praxe, arquivem-se.

P.I.C.

São Paulo, 30 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA